

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8131/2561

ธนาคาร พ.
บริษัท ช. กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4

จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับจ้างกับ A โดยมีข้อสัญญาระบุว่าจำเลยที่ 1 จะต้องจัดหาหลักทรัพย์ประกันการปฏิบัติงานโดยหนังสือค้ำประกันต้องเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยมีรูปแบบและเนื้อหาตามที่กำหนดและต้องจัดทำโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก A หนังสือค้ำประกันที่ A กำหนดให้จำเลยที่ 1 จัดหาให้ นั้นต้องมีข้อความสำคัญระบุว่า เมื่อธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันได้รับหนังสือเรียกร้องจาก A ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันต้องชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันทันที อันเป็นการที่ต้องชำระเงินเพียงเพราะได้รับหนังสือเรียกร้องดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบว่า จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจริงหรือไม่ เพราะไม่ว่าจะมีข้อโต้แย้งหรือไม่ ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันก็ไม่อาจปฏิเสธการจ่ายเงินดังกล่าวได้เนื่องจากมีข้อความตอนต้นว่า ธนาคารตกลงรับรองและรับประกันต่อ A อย่างไม่มีเงื่อนไขและปราศจากสิทธิในการแก้ต่างหรือฟ้องแย้งใด ไม่ว่าในนามของธนาคารหรือจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นข้อความแสดงถึงการสละสิทธิในการต่อสู้คัดค้านหรือโต้แย้ง และการที่ A กำหนดรายละเอียดของหนังสือค้ำประกันที่จำเลยที่ 1 ต้องจัดหาให้ A โดยธนาคาร ส. สาขาโตโฮ สามารถออกหนังสือค้ำประกันที่มีรายละเอียดดังกล่าวได้และจำเลยที่ 1 ทำคำขอให้โจทก์ออกหนังสือค้ำประกันโดยมี

ข้อความที่รับกับข้อความตามหนังสือคำประกันที่ A ต้องการดังกล่าว รวมทั้งการที่หนังสือคำประกันการปฏิบัติงานที่โจทก์ออกไปตามข้อความที่ A ต้องการ แสดงว่าการที่ผู้ว่าจ้างต้องการหนังสือคำประกันที่มีข้อความเช่นนี้และการที่ธนาคาร ส. สาขาโตะฮา สามารถออกหนังสือคำประกันเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันเป็นปกติของสถาบันการเงินในทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างได้รับหลักประกันของสถาบันการเงินที่มั่นคง และเรียกร้องให้ชำระเงินได้รวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาได้โดยเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาแก่ผู้รับจ้างและธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกัน ส่วนปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก็สามารถว่ากล่าวกันต่างหากได้ ข้อตกลงนี้แม้จะมีลักษณะที่ธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันถูกเรียกร้องให้ชำระเงินได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องคำประกัน แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้ามทำข้อตกลงเกี่ยวกับหนังสือคำประกันของธนาคารในลักษณะดังกล่าวและไม่เป็นการพ้นวิสัย เมื่อโจทก์จะต้องออกหนังสือคำประกันตามคำขอของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีข้อความว่าโจทก์ต้องชำระตามหนังสือคำประกันเมื่อได้รับหนังสือเรียกร้องให้ชำระเงินจากธนาคาร ส. ในประเทศไทยโดยไม่มีสิทธิคัดค้านไม่ว่าด้วยประการใด โจทก์จึงกำหนดข้อสัญญาในคำขอของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ออกหนังสือคำประกันที่ระบุถึงการยอมให้โจทก์ชำระเงินตามหนังสือคำประกันได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบก่อน และจำเลยที่ 1 สละสิทธิที่จะหักทวงการเงินของโจทก์ ทั้งจะต้องชดใช้เงินที่โจทก์ชำระไปดังกล่าวแก่โจทก์ด้วยเงื่อนไขในการที่โจทก์ต้องชำระเงินตามหนังสือคำประกันนั้นพิจารณาเฉพาะการได้รับหนังสือเรียกร้องเท่านั้น ไม่ต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเพราะปฏิบัติผิดสัญญาต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างหรือไม่ จึงไม่ใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 แก่โจทก์ โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 และของจำเลยที่ 2 ด้วย โจทก์จึงเป็นทั้งเจ้าหนี้สามัญผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้และเป็นเจ้าหนี้จำนองผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญโดยมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำนองด้วย เมื่อโจทก์ฟ้องโดยใช้สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวและมีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบถ้วนให้บังคับจำนองที่ดินรวมตลอดถึงทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน อันเป็นการฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องเต็มตามสิทธิที่โจทก์มีอยู่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้ให้ยึดที่ดินจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ในวงเงินจำนองพร้อมดอกเบี้ย และให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าบังคับชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 114,699,533.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 106,590,032.57 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2 และทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งห้าให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกัน 100,916,489.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี นับแต่วันที่ 22

มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป และร่วมกันชำระหนี้ตามบัญชีกระแสรายวัน 5,336,616.72 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระให้ ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 41993 และ 41994 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาดชำระ หนี้แก่โจทก์ในวงเงินจำนองพร้อมดอกเบี้ยและให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้า บังคับชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ กับให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แผนกคดีผู้บริโภค พิพากษากลับ ยกฟ้องจำเลยทั้งห้า แต่ ไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะฟ้องใหม่ในเรื่องค่าธรรมเนียมตามหนังสือคำประกันภายใน กำหนดอายุความ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลยทั้งห้า โดย กำหนดค่าทนายความให้จำเลยที่ 1 รวม 40,000 บาท กำหนดค่าทนายความในศาล ชั้นต้นให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 คนละ 5,000 บาท

โจทก์ฎีกาโดยศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันรับฟังได้ เป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย พ.ศ.2536 และเป็นสถาบันการเงิน จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็น นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับเหมาช่วงงานระบบ อิเล็กทรอนิกส์โรงซ่อมบำรุงเครื่องบิน เอ และ บี ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาแห่ง ใหม่ รัฐกาตาร์ จากกิจการร่วมค้า แอคเตอร์ เอส.เอ./อัล ดาร์วีซ เอ็นจิเนียริง ดับเบิล ยู.แอล.แอล./คอสตรูชันนิ ซิโมไล อาร์มานโด เอสพีเอ/กิจการร่วมค้า ไชบาร์โก มหาชน (Aktor S.A./AL Darwish Engineering W.L.L./Costruzioni Cimolai

Armando Spa/Cybarco Plc Joint Venture) หรือ เอดีซีซี เจวี (ADCC JV) และเอ
ดีซีซี เจวี ต้องการหนังสือค้ำประกันของธนาคารสากลที่มีสำนักงานสาขาในรัฐกาตาร์
ในที่สุดจำเลยที่ 1 จะให้ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์ สาขาโดฮา ในรัฐกาตาร์เป็นผู้
ออกหนังสือค้ำประกันโดยติดต่อผ่านทางโจทก์และธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์
(ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอให้
โจทก์ออกหนังสือค้ำประกันในนามของโจทก์ไปยังธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์
(ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการค้ำประกันในการที่ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ติดต่อดำเนินการให้ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์ สาขาโดฮา
รัฐกาตาร์ ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานและหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่า
งานล่วงหน้าตามสัญญารับเหมาช่วงดังกล่าวรวม 2 ฉบับ ในวงเงินฉบับละ
11,999,720 ريالกาตาร์ และโจทก์ได้ออกหนังสือค้ำประกัน 2 ฉบับ ตามคำขอของ
จำเลยที่ 1 ให้แก่ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็น
ประกันในการที่ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์ สาขาโดฮา รัฐกาตาร์ ออกหนังสือค้ำ
ประกันการปฏิบัติงานและหนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้าของจำเลยที่ 1 ให้แก่
เอดีซีซี เจวี และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันกับโจทก์ โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 จำเลยที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกัน 2
ฉบับ ในวงเงินฉบับละ 12,000,000 ريالกาตาร์ วันที่ 9 เมษายน 2551 จำเลยที่ 2
ทำสัญญาค้ำประกัน 2 ฉบับ ในวงเงินฉบับละ 12,000,000 ريالกาตาร์ และจำเลยที่
3 กับที่ 4 ร่วมกันทำสัญญาค้ำประกัน 2 ฉบับ ในวงเงินฉบับละ 12,000,000 ريالกา
ตาร์ เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้
ร่วม และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจดทะเบียนจำนองที่ดิน
โฉนดเลขที่ 41993 และ 41994 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของ
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ในวงเงิน 44,190,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อ
ปี ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด์ (ไทย) จำกัด

(มหาชน) แจ้งทาง SWIFT ถึงโจทก์ว่าธนาคารแสดนดาร์ตชาร์เตอร์ด สาขาโตฮา รัฐกาตาร์ ได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ธนาคารดังกล่าวออกให้แก่เอดีซีซี เจวี เนื่องจากเอดีซีซี เจวี ใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือคำประกัน และต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2554 โจทก์ได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันของโจทก์ให้แก่ธนาคารแสดนดาร์ตชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,301,160.94 ดอลลาร์สหรัฐ

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ กับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ที่เป็นปัญหาเดียวกัน และเห็นสมควรวินิจฉัยรวมกันไปว่า ข้อตกลงในการที่จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์ออกหนังสือคำประกันซึ่งให้จำเลยที่ 1 ตกลงสละสิทธิหรือคัดค้านการจ่ายเงินตามหนังสือคำประกันเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 หรือไม่ และจำเลยทั้งห้าต้องรับผิดชอบในหนี้ตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพหรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น และในวรรคสาม (1) และ (2) บัญญัติให้ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนวรรคสี่บัญญัติว่า ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสามจะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

ส่วนข้อสัญญาตามคำขอของจำเลยที่ 1 ที่ขอให้โจทก์ออกหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาจ้างระหว่างเอดีซีซี เจวี กับจำเลยที่ 1 ไปยังธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาโศธา รัฐกาตาร์ ออกหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 ไปยังเอดีซีซี เจวี ซึ่งเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่โจทก์จัดทำและให้จำเลยที่ 1 ลงนามนั้นมีข้อความในข้อ 3 ระบุถึงกรณีที่โจทก์ถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามภาระภายใต้หนังสือคำประกัน จำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์ชำระเงินตามที่ถูกร้องได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบก่อน หรือไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 1 ก่อน รวมทั้งจำเลยที่ 1 สละสิทธิที่จะหักทวงคัดค้านการจ่ายเงินของโจทก์ แม้ว่าจำเลยที่ 1 หรือโจทก์จะมีข้อต่อสู้ที่จะยกขึ้นต่อสู้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของหน้าที่เอกสารความรับผิดชอบตามสัญญา หรือข้อต่อสู้อื่นใดก็ตาม และหากโจทก์จ่ายเงินไปแทนจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 ตกลงที่จะชดใช้ให้แก่โจทก์จนครบถ้วนในทันทีที่ได้รับแจ้งจากโจทก์ ข้อสัญญาดังกล่าวนี้นี้เมื่อพิจารณาประกอบกับหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานของโจทก์ที่ออกให้แก่ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นได้ว่า เมื่อโจทก์จะต้องออกหนังสือคำประกันตามคำขอของจำเลยที่ 1 ซึ่งจะมีข้อความว่า โจทก์ต้องชำระตามหนังสือคำประกันเมื่อได้รับหนังสือเรียกร้องให้ชำระเงินจากธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีสิทธิคัดค้านไม่ว่าด้วยประการใด โจทก์จึงกำหนดข้อสัญญาในคำขอของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ออกหนังสือคำประกันตามความในข้อ 3 ที่ระบุถึงการยอมให้โจทก์ชำระเงินตามหนังสือคำประกันได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบก่อนและจำเลยที่ 1 สละสิทธิที่จะหักทวงการจ่ายเงินของโจทก์ ทั้งจะต้องชดใช้เงินที่โจทก์ชำระไปแก่โจทก์ด้วย โดยเงื่อนไขในการที่โจทก์ต้องชำระเงินตามหนังสือคำประกันนั้น พิจารณาเฉพาะการได้รับหนังสือเรียกร้องเท่านั้นไม่ต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเพราะปฏิบัติผิดสัญญาต่อเอดีซีซี เจวี ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้าง

หรือไม่ เช่นนี้ เมื่อพิจารณาประกอบข้อความตามหนังสือคำประกันของโจทก์ ที่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า THIS COUNTER GUARANTEE IS SUBJECT TO THE INTERNATIONAL STANBY PRACTICES 1998 (ISP98) และโจทก์จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยว่า หนังสือคำประกันตอบแทนฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของแนวปฏิบัติการสำรองแทนระหว่างประเทศ พ.ศ.2541 (ISP98) และมีข้อความเช่นเดียวกันนี้อยู่ในตัวอย่างหนังสือคำประกัน ซึ่งฝ่ายจำเลยจัดทำคำแปลเป็นทำนองเดียวกับคำแปลของโจทก์ว่า หนังสือคำประกันฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของระเบียบว่าด้วยการคำประกันนานาชาติ 2552 (ที่ถูก 2541) ส่อแสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติการคำประกันนานาชาติ ค.ศ.1998 (ISP98) ฉบับนี้น่าจะเป็นข้อปฏิบัติหรือประเพณีที่ปฏิบัติกันในการออกหนังสือคำประกันในทางการค้าระหว่างประเทศและอาจเป็นปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้นที่นำมาใช้ในการพิจารณาปัญหาว่าข้อสัญญาข้อ 3 ดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยที่ 1 เกินสมควรหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4 วรรคสี่ ประกอบ มาตรา 10 (2) แต่โจทก์กลับไม่นำสืบถึงรายละเอียดของแนวปฏิบัติการคำประกันนานาชาติ ค.ศ.1998 (ISP98) ดังกล่าวแต่อย่างใด ก็ส่อแสดงว่า การที่ผู้ว่าจ้างต้องการหนังสือคำประกันที่มีข้อความเช่นนี้และการที่ธนาคารสามารถออกหนังสือคำประกันเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันเป็นปกติของสถาบันการเงินในทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างดังเช่นเอตชีซี เจวี ในเรื่องนี้ได้รับหลักประกันของสถาบันการเงินที่มั่นคง แน่นนอน และเรียกร้องให้ชำระเงินได้รวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาได้โดยเร็ว โดยไม่ต้องเรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาแก่ผู้รับจ้างและธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเสียก่อนและไม่เป็นปัญหาแก่ธนาคารที่จะต้องตรวจสอบว่าฝ่ายใดผิดสัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากจนในที่สุดก็ต้องมีการฟ้องร้องกันเสียก่อนดังกล่าว

ส่วนปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก็สามารถว่ากล่าวกันต่างหากได้โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ดีด้วยกันอยู่แล้ว และแม้ข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีลักษณะที่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันถูกเรียกร้องให้ชำระเงินได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องค้ำประกันก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้ามทำข้อตกลงเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันของธนาคารในลักษณะดังกล่าวและไม่เป็นการพ้นวิสัย ทั้งการที่โจทก์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 ว่า "ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้าและการลงทุน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน รับประกันความเสี่ยงหรือให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินั้น" เมื่อพิจารณาถึงการที่โจทก์ให้บริการในเรื่องการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อให้ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาโดฮา รัฐกาตาร์ ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 ต่อเอดีซีซี เจวี โดยให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างเอดีซีซี เจวี กับจำเลยที่ 1 ดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้จำเลยที่ 1 ได้รับจ้างช่วงทำงานให้แก่เอดีซีซี เจวี ตามความต้องการของจำเลยที่ 1 ก็เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าบริการในต่างประเทศของจำเลยที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ดังกล่าวแล้ว ตรงกันข้ามหากโจทก์ไม่ออกหนังสือค้ำประกันที่มีข้อความตามที่เอดีซีซี เจวี ต้องการดังกล่าวก็กลับจะทำให้เกิดผลเสียแก่จำเลยที่ 1 เพราะเอดีซีซี เจวี กำหนดในสัญญาว่าหนังสือค้ำประกันที่จำเลยที่ 1 จัดมาให้ต้องมีข้อความดังกล่าวและการที่จะขอให้ธนาคารแสดนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาโดฮา รัฐกาตาร์ ออกหนังสือค้ำประกันที่มีข้อความตามที่เอดีซีซี เจวี กำหนดไว้ดังกล่าวได้ ธนาคารดังกล่าวก็ย่อมต้องการหลักประกันสำหรับความเสี่ยงที่เมื่อธนาคารดังกล่าวชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันที่ตนออกไปดังกล่าวแล้วจะได้รับชดใช้เงินที่ชำระไปคืนหรือไม่ ดังนั้นย่อมจำเป็นที่จำเลยที่ 1 ต้องขอให้

โจทก์ออกหนังสือคำประกันให้ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการให้ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาโศหา รัฐกาตาร์ ออกหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 ให้แก่เอดีซีซี เจวี โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินตามหนังสือคำประกันเมื่อได้รับหนังสือเรียกร้องโดยไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านเช่นเดียวกันเพื่อให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาโศหา อันจะทำให้ธนาคารดังกล่าวตัดสินใจออกหนังสือคำประกันจำเลยที่ 1 ให้แก่เอดีซีซี เจวี ตามความต้องการของจำเลยที่ 1 เพราะมีหลักประกันตามหนังสือคำประกันของโจทก์ และโจทก์จะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินที่โจทก์ชำระให้แก่ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือคำประกันของโจทก์เป็นทอดสุดท้าย ซึ่งโจทก์ก็ต้องป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ทำสัญญาคำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์รวมทั้งให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนจ่านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 แต่หากโจทก์ปฏิเสธไม่ออกหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 โดยมีข้อความการชำระเงินตามข้อความที่เอดีซีซี เจวี กำหนดไว้ดังกล่าว ก็ทำให้ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาโศหา รัฐกาตาร์ ไม่มีหลักประกันอันมั่นคงเพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคารในการออกหนังสือคำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ให้แก่เอดีซีซี เจวี และธนาคารดังกล่าวย่อมไม่ออกหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 ให้แก่เอดีซีซี เจวี ก็จะทำให้จำเลยที่ 1 ไม่สามารถทำงานรับจ้างช่วงกับเอดีซีซี เจวี ได้ตามสัญญาจ้าง ซึ่งกลับจะเป็นการไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนจำเลยที่ 1 และเมื่อมีการเรียกร้องให้โจทก์ชำระเงินตามหนังสือคำประกันของโจทก์ก็เป็นหน้าที่ตามข้อผูกพันในอันที่จะต้องชำระเงินตามหนังสือคำประกันของโจทก์โดยไม่อาจโต้แย้งคัดค้านได้ดังที่ได้ให้สัญญาไว้ในหนังสือคำประกัน และหากโจทก์ปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามหนังสือคำประกันของโจทก์ก็จะทำให้โจทก์เสียความน่าเชื่อถืออันอาจจะทำให้ต่อไปภายหน้าโจทก์อาจ

ไม่ได้ได้รับความเชื่อถือในการที่จะออกหนังสือคำประกันให้แก่ลูกค้ารายอื่นอีกหลายราย อันเป็นความเสียหายแก่ส่วนรวม จึงเห็นได้ว่า การที่โจทก์ปฏิบัติตามภาระในการชำระเงินตามหนังสือคำประกันมิใช่เหตุที่จำเลยที่ 1 จะกล่าวอ้างได้ว่าโจทก์ไม่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนจำเลยที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ และถือไม่ได้ว่า ข้อตกลงและการปฏิบัติของโจทก์เกี่ยวกับหนังสือคำประกันดังกล่าวมานั้นขัดต่อบทกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของธนาคารโจทก์ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536 มาตรา 7 ทั้งข้อตกลงเช่นนี้ก็ไม่มีลักษณะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงขอที่คู่สัญญาจะทำข้อสัญญาดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาได้ แม้จะแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคำประกันก็ตาม ส่วนจะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่จะให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาถึงการที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับจ้างช่วงกับเอ ดีซีซี เจวี โดยกำหนดให้จำเลยที่ 1 จัดหาหนังสือคำประกันที่มีข้อสัญญาดังกล่าวให้ เอ ดีซีซี เจวี จึงเป็นกรณีจำเป็นที่จำเลยที่ 1 ต้องขอให้โจทก์ออกหนังสือคำประกันที่มีข้อความตามที่เอ ดีซีซี เจวี กำหนดและทำสัญญากับโจทก์ตามคำขอให้ธนาคารออกหนังสือคำประกัน ข้อ 3 ดังกล่าวมาข้างต้นเพื่อให้รับกันกับหนังสือคำประกันที่โจทก์จะออกให้แก่ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงแก่ธนาคารดังกล่าวในอันที่จะดำเนินการให้ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาโดฮา รัฐกาตาร์ ออกหนังสือคำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 แก่เอ ดีซีซี เจวี ได้สำเร็จตามความประสงค์ของจำเลยที่ 1 และเอ ดีซีซี เจวี ตามสัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ 1 กับเอ ดีซีซี เจวี มิฉะนั้นจำเลยที่ 1 ก็จะไม่สามารถรับจ้างทำงานให้เอ ดีซีซี เจวี ได้ตามสัญญาจ้างดังกล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่ใช่ข้อสัญญาที่โจทก์ประสงค์จะเอาเปรียบจำเลยที่ 1 หรือจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพราะจำเลยที่ 1 มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าโจทก์ และไม่ว่าจำเลยที่ 1 จะติดต่อกับสถาบัน

การเงินอื่นใด จำเลยที่ 1 ก็ต้องขอให้ธนาคารออกหนังสือคำประกันไปตามที่เอดีซีซี เจวี กำหนด และแม้ข้อสัญญาดังกล่าวอาจทำให้จำเลยที่ 1 รับภาระมากกว่าที่ลูกหนี้มีต่อผู้ค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ก็เป็นกรณีที่เกิดจากการที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากับเอดีซีซี เจวี ไว้เช่นนั้น จึงเป็นความจำเป็นของจำเลยที่ 1 ที่ต้องตกลงทำสัญญากับโจทก์ตามข้อสัญญาดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่จำเลยที่ 1 ตกลงไว้กับเอดีซีซี เจวี ย่อมถือได้ว่าข้อสัญญาเกิดขึ้นจากความประสงค์ของจำเลยที่ 1 ที่จะตกลงแตกต่างจากบทกฎหมายคำประกันดังกล่าวเอง จึงต้องบังคับกันตามเจตนาในการทำสัญญาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ตามบทกฎหมายในเรื่องสัญญาซึ่งถือไม่ได้ว่าภาระของจำเลยที่ 1 ตามข้อสัญญาอันเกิดจากเจตนาความประสงค์ของจำเลยที่ 1 เช่นนี้ ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติและถือไม่ได้ว่าข้อสัญญาตามคำขอให้ธนาคารออกหนังสือคำประกัน ข้อ 3 เป็นข้อสัญญาที่ทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยที่ 1 เกินสมควร จึงมิใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4 ย่อมบังคับกันได้ตามข้อสัญญาดังกล่าว กล่าวคือเมื่อโจทก์ได้รับหนังสือเรียกร้องให้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันของโจทก์จากธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โจทก์ต้องชำระเงินตามหนังสือคำประกันโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญาต่อเอดีซีซี เจวี หรือไม่ และเมื่อโจทก์ชำระเงินไปดังกล่าวแล้วก็ชอบที่จะเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่โจทก์ชำระไปตามข้อสัญญาข้อ 3 ดังกล่าว ดังนั้น การที่โจทก์ชำระเงินแก่ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อธนาคารดังกล่าวส่งหนังสือเรียกร้องถึงโจทก์โดยไม่ตรวจสอบก่อนว่าจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญาต่อเอดีซีซี เจวี หรือไม่ เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการชำระเงินตามหนังสือคำประกันโดยชอบ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินที่โจทก์ชำระไปตามหนังสือคำประกันพร้อมทั้งดอกเบี้ยได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แผนกคดีผู้บริโภค

พิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้โดยวินิจฉัยว่า ข้อสัญญาตามคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน ข้อ 3 เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและโจทก์ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันโดยไม่ตรวจสอบว่า จำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญาต่อเอทีซีซี เจวี หรือไม่เสียก่อน เป็นการชำระเงินที่ไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ในปัญหา 2 ข้อนี้ฟังขึ้น แต่อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ในปัญหาดียวกันนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งห้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แผนกคดีผู้บริโภค ยังไม่ได้วินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วนไม่ถูกต้อง ที่ถูกหากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้ต้องให้บังคับคดียึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดก่อน หากไม่พอชำระหนี้จึงให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบถ้วนนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 แก่โจทก์โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมและจำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 และของจำเลยที่ 2 ด้วย โจทก์จึงเป็นทั้งเจ้าหนี้สามัญผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้และเป็นเจ้าหนี้จำนองผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญโดยมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำนองด้วย เมื่อโจทก์ฟ้องโดยใช้สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวและมีคำขอท้ายฟ้องว่า หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบถ้วนให้บังคับจำนองที่ดินรวมตลอดถึงทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน อันเป็นการฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องเต็มตามสิทธิที่โจทก์มีอยู่ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาในส่วนนี้ว่า หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 41993 และ 41994 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่

โจทก์ในวงเงินจำนองพร้อมดอกเบี้ย และให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าบังคับชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งห้าข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาล นอกจากค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นคืนให้จำเลยทั้งห้าไปแล้วให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-เมทินี ชโลธร-สนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นางศรีอรุณ มีแสง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นางสาวเสาวลักษณ์ จิระรัตนานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นฎบ1951/2555

ต้น

หมายเหตุ